

《【문제2】 소송상 항변에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송상 항변의 의의, 부인과의 구별, 항변의 종류, 제출요건과 시기

I. 문제의 제기

- 소송상 항변이란 원고가 주장하는 청구원인 사실(요건사실)을 피고가 인정하면서도, 그와는 별개의 사실을 주장하여 원고 청구의 당부나 소송의 적법성을 다투는 방어방법을 의미한다. 이는 원고의 주장 사실 자체를 부정하는 부인과 구별되는 개념으로, 피고에게 증명책임이 전환된다는 점에서 실무상 매우 중요한 의미를 갖는다. 항소심 등 소송의 각 단계에서 항변의 제출 시기와 방식에 따라 소송의 결과가 크게 달라질 수 있다. 이하에서는 항변의 의의와 부인과의 구별 실익, 그리고 소송법상 항변과 본안전 항변 등 그 구체적인 종류에 대해 설명한다.

II. 항변의 의의와 부인의 구별

1. 항변의 개념

- 원고가 주장하는 요건사실의 존재를 전제로 하되, 그 법률효과의 발생을 저지·멸실·정지시키기 위하여 피고가 제출하는 별개의 독립된 사실 주장을 말한다.

2. 부인과의 구별 및 실익

(1) 개념적 차이

- 부인은 원고가 주장하는 사실 자체를 부정하는 것이며, 항변은 원고의 주장은 맞으나 다른 사정이 있다는 이유로 반박하는 것이다. 예를 들어 돈을 빌린 적 없다는 부인이지만, 돈을 빌렸으나 갚았다는 변제항변이다.

(2) 증명책임의 소재

- 부인의 경우 원고가 해당 사실의 존재를 증명해야 하지만, 항변의 경우 항변 사실에 대한 증명책임은 이를 주장하는 피고에게 전적으로 귀속된다.

III. 소송상 항변의 종류

1. 본안전 항변

- 원고의 청구가 적법한 소송요건을 갖추지 못하였음을 이유로 소를 부적법 각하해 달라고 구하는 방어방법이다.

(1) 부적법한 소의 제기 주장

- 관할위반, 중복소송, 재소금지 위반, 당사자 적격의 결여 등을 주장하는 것이 이에 해당한다.

(2) 직권조사사항과의 관계

- 소송요건은 법원의 직권조사사항이나, 당사자가 이를 지적하는 것은 법원의 주의를 촉구하는 의미의 본안전 항변이 된다. 다만, 임의관할이나 중재합의와 같은 변론관할의 경우에는 당사자의 항변이 있어야만 비로소 고려된다.

2. 본안상 항변

- 원고의 청구가 실체법상 이유 없음을 주장하여 청구기각 판결을 구하는 방어방법이다. 이는 법률효과에 따라 세 가지로 세분된다.

(1) 장애항변(성립저지 항변)

- 권리의 성립 자체를 방해하는 사실을 주장하는 것이다. 예 : 의사무능력, 선량한 풍속 위반(민법 제103조), 통정허위표시 등.

(2) 멸실항변(권리소멸 항변)

- 일단 유효하게 성립한 권리를 사후적으로 소멸시키는 사실을 주장하는 것이다. 예 : 변제, 소멸시효 완성, 상계, 면제 등.

(3) 저지항변(권리행사 저지 항변)

- 권리의 존재는 인정하나 그 행사를 일시적 또는 영구적으로 저지할 수 있는 사실을 주장하는 것이다. 예 : 동시이행의 항변권, 보증인의 최고·검색의 항변권 등.

IV. 항변의 제출 요건과 시기

1. 적기제출주의

- 민사소송법은 소송의 지연을 방지하기 위하여 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하도록 규정하고 있다.

2. 실기한 공격방어방법의 각하

- 피고가 고의 또는 중대한 과실로 항변을 뒤늦게 제출하여 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 법원은 직권 또는 상대방의 신청에 의해 해당 항변을 각하할 수 있다.

V. 결론

- 소송상 항변은 피고가 자신의 권리를 보호하기 위해 행사하는 가장 강력한 법적 수단 중 하나이다. 특히 변제, 상계, 소멸시효와 같은 본안상 항변은 사건의 실체적 진실을 밝히는 데 핵심적인 역할을 한다. 당사자는 항변의 종류에 따른 증명책임을 명확히 인지하여야 하며, 법원은 제출된 항변이 단순한 부인인지 아니면 독립된 항변인지를 엄격히 구별하여 재판의 공정성과 효율성을 도모해야 한다. 이하에서는 이러한 항변권 행사가 신의성실의 원칙에 반하지 않도록 절차 내에서 적절히 통제되어야 한다.